例说工期顺延与工期索赔中的法律问题

文/刘志强



刘志强

案情简介

2007年7月5日，华星公司与某市第二建筑公司（以下简称二建公司）签订《建设工程施工合同》一份，约定由二建公司承包华星公司开发的某大厦桩基、土建等工程，合同总价3269万元，工期为420天，双方在专用条款中约定，如因乙方（二建公司）原因造成的工期延误，则乙方按合同价格的万分之四/天向甲方（华星公司）支付违约金。在建设过程中，因各种原因导致工期拖延，二建公司实际竣工时间为551天，比约定工期迟延了131天，双方结算过程中出现纠纷，华星公司要求按照约定扣除工期延误的违约金，二建公司则不同意。后二建公司向法院提起诉讼，要求华星公司支付拖欠的工程款629万元，华星公司遂提起反诉，要求二建公司支付违约金720.4876万元。针对华星公司的要求，二建公司提出，双方在合同专用条款中约定，华星公司应在合同签订后的10日内（即2007年7月15日前），按合同价款支付20%的工程预付款，而该笔款项到 2007年10月15日才支付，而且在施工过程，华星公司多次未按照约定支付工程进度款，累计拖延付款时间已超过131天，因甲方违约在先，乙方可以顺延工期。此外，在工程进行中，华星公司还多次进行工程的变更，因此也导致了工期的延误。所以，华星公司应当自行承担工期延误的后果，二建公司不应当承担违约责任。

针对二建公司提出的抗辩理由，华星公司认为工程预付款与工程进度款虽然在支付上有过迟延，但二建公司并未在合同约定期限内提出过工期索赔，并且预付款和进度款的支付迟延并未导致二建公司的停工，并举出工程联系单与会议纪要等证据，证明在迟延付款期间，二建公司的施工仍在正常进行。同样，在工程发生变更后，二建公司也未在合同约定的期限内提出工期索赔，并且发生变更的工程也不在工程的关键路径上，不会导致工期受影响。因此，二建公司的抗辩理由不能成立。

工期顺延与工期索赔的法律分析

本案中，出现了一个在建设工程施工过程中非常典型的问题，即在开工前发包人迟延支付预付款或者在工程进行过程中，发包人没有按照约定的期限支付工程进度款时，承包人没有要求工期顺延或者提出工期索赔，并且仍然进行了正常施工。当承包人没有按照规定的工期完成工程时，其是否能以发包人迟延付款作为工期延误的抗辩理由?

关于工期顺延及工期索赔的问题，建设工程相关法律、法规中少有涉及，调整发包人与承包人在这方面权利义务关系的主要依据双方所签订的施工合同。现在承、发包方使用的合同文本大都为住房和城乡建设部、国家工商行政管理局于1999年制定的《建设工程施工合同》（GF—1999—0201）（以下简称《示范文本》）。从契约角度来说，当事人之间约定的条款只要不违反国家法律、行政法规的强制性规定，即成为当事人之间的法律，各方必须严格遵守。在《示范文本》第13.1中对工期延误的七种情形进行了约定，因这七种原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延，其中第2项为“发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；”第4项为“设计变更和工程量增加”。另外，《示范文本》13.2约定：“承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。”从以上约定可以看出，发包人迟延支付预付款、进度款可能导致工期顺延有个前提条件，即发包人的迟延支付行为，导致了施工不能正常进行的后果。另外，承包人还应当在约定的期限内向工程师提出书面报告，要求顺延工期，同时约定工程师在收到报告的一定期限内不予确认也不提出修改意见的，即视为同意顺延工期，但该条中并未约定如果承包人未在约定期限内提出顺延工期的书面报告，即失去了此项权利。承包人除可以适用以上约定要求顺延工期外，还可以依据《示范文本》第36条关于索赔的约定，向发包人提出工期索赔，但该条中依然没有承包人未在一定期限内提出索赔要求时，即失去了此项索赔权利的约定。既然在《示范文本》中并未提及承包人未在约定期限内提出工期顺延或者工期索赔要求时，承包人即失去此项权利，则关于承包人是否会因此失权的问题只能依据法律规定。民法中的失权是指原有权利的丧失，是指当事人（含第三人）原本享有的权利因某种原因或事由的发生而丧失。这些权利之所以会因某种原因或事由的发生而丧失，是因为法律规定或当事人约定权利人享有这些权利的同时，也设置了这些权利行使和丧失的条件。因为任何一种权利的行使和存在都是具体的、有条件的，当存在的具体条件不复存在时，失权的结果就自然会发生。在双方无约定的情况下，我国相关法律中也并无承包人未在约定期限内提出工期顺延或者工期索赔要求时即为失权的规定。因此，承包人未在约定的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

期限内提出工期顺延或者工期索赔的，并不必然丧失此权利。

有学者认为，《示范文本》中关于签证期限的约定属于诉讼时效或者除斥期间，在该期限内承包人未提出工期顺延或者工期索赔的要求，则丧失了胜诉权。笔者认为，以上观点有失偏颇。首先，民事诉讼时效是指权利人经过法定期限不行使自己的权利，依据法律规定其胜诉权便归于消灭的制度。 一般权利人向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为两年，法律另有规定的除外。除斥期间是指法律规定某种民事实体权利存在的期间。权利人在此期间内不行使相应的民事权利，则在该法定期间届满时导致该民事权利的消灭。从以上定义可知，诉讼时效与除斥期间都源自于法律的直接规定，当事人无法在合同中自行约定。如果发包人与承包人在施工合同中约定：“承包人未在约定的期限内提出工期顺延或者工期索赔要求的，则丧失此项权利”，此种约定的性质属于我们前面所说的失权约定，符合约定的条件时，承包人即失去了此种权利。

也有人认为，“对承包人的签证权不加时间限制，无疑将置发包人于不利状态，因为发包人在签证过程中，其掌握的专业知识本来就无法与承包人抗衡。而将该期限视为时效的情况下，凡期限届满，即视为不行使相应权利的承包人放弃了签证权利或索赔权利，发包人可以以此作为证据的代用，避免举证的困难，这样有利于在短时期内保存证据，解决争端”。我们相信，在住房和城乡建设部、国家工商行政管理局制定《示范文本》的相应条款时，应当有过这方面的考虑，但也许是出于承、发包双方力量平衡的考虑或者是在制定具体条文时的疏漏，在明确约定承包人提出工期顺延或者工期索赔期限的同时，并未明确承包人未在该期限内提出该要求的后果，当合同中对此无明确约定时，我们只能适用法律所规定的诉讼时效来调整此种关系，即承包人未在规定的诉讼时效（两年）内提出顺延工期或者工期索赔的要求，即丧失相应的胜诉权。

另外，前面曾分析到，发包人迟延支付预付款、进度款可能导致工期顺延还有个前提条件，即发包人的迟延支付行为，导致了施工不能正常进行的后果。如发包人虽然迟延付款，但承包人自行筹款进行施工，并未影响到施工进度。在此种情况下，如承包人提出顺延工期或者工期索赔的要求，发包人不予认可是有依据的，也是合理的。此时，承包人只能因发包人迟延付款向其主张利息损失及其他损失，如双方对此约定了违约责任，则承包人还可以依据合同向发包人主张违约责任。但在同样的情形下，如果发包人认可了承包人的工期顺延或者工期索赔要求，在双方发生纠纷时，发包人再以迟延付款行为并未影响到承包人的施工进度为理由，否定此前的认可行为，发包人的此种主张能否获得法律支持呢？从工程角度分析，发包人签字认可了承包人的工期顺延或工期索赔要求的行为，属于工程上的签证。而工程签证是合同双方在履行施工承包合同过程中，按照合同约定或经协商一致，对施工过程中发生的各种费用、工期顺延、经济索赔等所达成的意思表示一致的补充协议。而作为补充协议，则意味着双方已经一致同意对原协议的某些内容进行了变更，双方当事人必须履行已经签订的补充协议。因此，当发包人认可了承包人的工期顺延或者工期索赔要求后，发包人再以迟延付款行为并未影响到承包人的施工进度为理由，否定此前的认可行为，该否认行为不能获得法律的支持。

工程变更中的关键路径问题分析

在本文开始的案例中，还有这样一个问题，即华星公司所主张的建设过程中所发生的变更并不在工程的关键路径上，因此变更不导致工期受影响。所谓关键路径指的是该工程最短需要完成的时间路径，关键路径上的活动持续时间决定了项目的工期，关键路径上所有活动的持续时间总和就是项目的工期。关键路径上的任何一个活动都是关键活动，其中任何一个活动的延迟都会导致整个项目完工时间的延迟。因此，只有在工程关键路径上的变更才可能导致工期顺延和工期索赔的后果，在这一点上，华星公司的主张是有道理的。但是，如果在发生非关键路径上的变更后，承包人提出的工期顺延或工期索赔要求得到了发包人的认可，该签证同样可以获得法律的支持，发包人不能再以变更不在工程关键路径上否定之前的认可行为。

律师提示

工期虽然与质量、造价并列为工程合同的三大要素，但通常在发包人与承包人看来，其重要性显然不如其他两者。但工期问题毕竟也关系着发包人与承包人的重大利益，在本文开始的案例中，发包人主张的工期违约金几乎达到工程合同价的四分之一。因此，在施工管理过程中，如果不重视工期的管理，也可能造成巨大的损失。从承包人的角度来说，当发生了可能导致工期顺延或者工期索赔的事项时，一定要按照合同约定的方式，在约定的时限内向发包人提出工期顺延或者工期索赔的要求，并注意保留好相关的书面文件。从发包人的角度来说，按照合同约定提供各种施工条件、按时支付预付款和进度款尤其重要，如果承包人提出工期顺延或者工期索赔要求，一定要仔细审核，对不符合条件的要求应当在约定时限内书面拒绝，防止发生拖延。

总之，工期管理在整个施工过程中，是一个细致而长期的工作，而其中的预防工作往往比事后的补救更为重要。承、发包双方除应当作好施工合同专用条款中关于合同工期、工期顺延、工期索赔方面的约定外，更应当重视工程建设过程中的工期签证与工期索赔的日常管理。

（作者单位：北京盈科（上海）律师事务所）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net